

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 7130/214

Betreft zaak: taxivervoer IJsselsteden de heer C

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 62 van de Mededingingswet.

I. Inleiding

1. Op 28 april 2011 heeft de Directie Mededinging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. (hierna: RMC) en IJsselsteden Beheers Groep B.V. (hierna: IJsselsteden) rapporten in zaak 7130 toegezonden wegens het vermoeden van het overtreden van de Mededingingswet (Mw) door deze ondernemingen.
2. Dezelfde rapporten zijn ook gezonden naar de natuurlijke personen van wie werd vermoed dat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtredingen, onder wie de heer [vertrouwelijk] hierna: de heer [C] en in e-mails ook [vertrouwelijk] van IJsselsteden.
3. Dit besluit betreft de heer [C], [leidinggevende] van IJsselsteden.
4. Bijlage 1 bevat het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad), kenmerk 7130/153, in welk besluit de Raad heeft vastgesteld dat IJsselsteden en RMC in van periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 artikel 6 Mw hebben overtreden. Deze bijlage, inclusief de daarin gedefinieerde termen, maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

II. Juridisch kader

5. Artikel 56 Mw luidt, voor zover van belang, als volgt:
 1. Ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid (...), kan de raad de overtreder:
 - a. een bestuurlijke boete opleggen;(...).

6. Artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt als volgt:

(....)

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

7. Artikel 51, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt als volgt:

Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolgning worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:

1. tegen die rechtspersoon, dan wel
2. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3. tegen de onder 1° en 2° genoemden tezamen.

8. Een natuurlijke persoon kan beboetbaar leiding geven aan een overtreding van een onderneming of ondernemersvereniging door actieve gedragingen, waarbij de overtreding door hem wordt bevorderd door middel van handelen, alsook door passieve gedragingen, waarbij de natuurlijke persoon de overtredingen doet bevorderen door nalaten.¹
9. Uit de jurisprudentie volgen minimumcriteria wanneer in ieder geval sprake is van leiding geven in de zin van 51 Sr:

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris — hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden — maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In deze situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te bevorderen”.²

10. De verplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming van een bepaalde gedraging, kan op meerdere natuurlijke personen tegelijkertijd rusten.³ In zo een geval kan aan één gedraging van de rechtspersoon door meerdere personen tegelijkertijd leiding worden gegeven.

¹ Vergelijk Hoge Raad 20 november 1984, NJ 1985, 355. Zie ook recentelijk Rechtbank Rotterdam 16 mei 2012, LJN: BW 6221.

² Hoge Raad 16 december 1986, NJ 1987, 321 (*Slavenburg II*), r.o. 5.1.1.

³ Hoge Raad 16 juni 1981, NJ 1981, 586 (*Papa Blanca*), r.o. 8.

11. Het leidinggeven vereist volgens vaste jurisprudentie dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet. Daartoe is in het geval van een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw voldoende dat sprake is van opzet op de gedragingen van de onderneming.⁴ Niet van belang is of degene die kennis heeft van de gedragingen *beoogt* een norm te overtreden. Een dergelijke verzwaarde vorm van opzet is niet vereist.⁵
12. De Raad heeft in zijn besluit met kenmerk 7130/153 geconcludeerd dat IJsselsteden artikel 6, eerste lid, Mw heeft overtreden. In het onderhavige besluit is aan de orde of de heer [C] daaraan feitelijk leiding heeft gegeven als bedoeld in artikel 5:1, derde lid, van de Awb, gelezen in samenhang met artikel 51, tweede lid, Sr.⁶

III. Feiten en omstandigheden

13. De Raad stelt in aanvulling op het sanctiebesluit met kenmerk 7130/153 waarin een overtreding van artikel 6 Mw door IJsselsteden is vastgesteld (bijlage 1), de navolgende feiten en omstandigheden vast.
14. De heer [C] was gedurende de betreffende periode (deels via Institorium Beheer B.V.) [leidinggevende] bij IJsselsteden.⁷
15. De Raad stelt vast dat de heer [C] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming op 18 december 2007 van de afspraken die de basis vormen van de overtreding van IJsselsteden. Zo volgt uit een e-mail van 17 december 2007 van de heer [A] ([leidinggevende] van RMC) dat de heer [C] en de heer [D] (IJsselsteden) contact hebben met hem over de overeenkomst:

*“Ik heb vanmiddag een vervolgesprek gehouden met IJsselsteden en alle onderwerpen doorgesproken, t/m aanbesteding VOM, etc. Ik wil dit verhaal morgenochtend doorsturen aan [C] en [D] en liefst die zelfde dag nog laten tekenen. Dus als het kan gaarne reactie voor 10:00 uur”.*⁸
16. Vervolgens hebben de heren [C] en [D] op 18 december 2007 meerdere malen contact met de heer [A] (RMC) om tot in detail overeenstemming te bereiken over de afspraken.

⁴ Hoge Raad 1 februari 2005, *NJ*2006, 421 (*SE Fireworks*), r.o. 7.5 en 7.6; Hoge Raad 12 januari 2010, *RvdW*2010, 168, r.o. 2.5.

⁵ Hoge Raad 18 maart 1952, *NJ*1952, 314, bevestigd in Hoge Raad 27 april 2007, *NJ*2007, 544, r.o. 3.3.

⁶ De Raad beschouwt opdracht geven als een bijzondere vorm van feitelijk leidinggeven en volstaat derhalve met de algemene term “leidinggeven”.

⁷ Dossierstuk 56, prisma-nummer 7130_43.

⁸ Dossierstuk 59, prisma-nummer 7130_41, bijlage 2.

“[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]

Hierbij de versie die eigenlijk aan jullie had moeten versturen.

Deze heb ik aangepast op basis van mijn tel. Gesprekje met [vertrouwelijk].

Ik hoor graag verder van jullie.

Mvrgr.

*[A]”.*⁹

“Beste [vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]

Ik heb jullie laatste wens verwerkt in een extra alinea bij punt 9.

Tevens nog even een enkele tekstfout (o.a bij de tenaamstelling) verbeterd.

Als jullie morgen laten weten of we er dan zoals verwacht definitief uit zijn, dan is het voor ons allen misschien leuk om nog voor de Kerst te tekenen.

Mvrgr.

*[A]”.*¹⁰

17. Hierna heeft de heer [C] de samenwerkingsovereenkomst met RMC van 18 december 2007 in zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van IJsselsteden ondertekend.¹¹
18. De heer [C] heeft zelf overigens bevestigd dat hij betrokken is geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst en dat vóór de totstandkoming van de overeenkomst diverse malen contact is geweest tussen IJsselsteden en RMC.¹²
19. De heer [C] is tevens betrokken geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden inzake de aanbestedingen in de periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010. De Raad leidt dit af uit het volgende.
20. De heer [C] heeft op 18 en 19 augustus 2008 een e-mailwisseling met een medewerker van RMC over de aanbesteding van het leerlingenvervoer Capelle. In die e-mailwisseling spreken de heer [C] en de medewerker van RMC elkaar aan op het feit dat er een overeenkomst is. Uit deze e-mailwisseling blijkt dat de heer [C] betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken.¹³

⁹ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 4.

¹⁰ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 5.

¹¹ Dossierstuk 60, met kenmerk 7130_42, bijlage 1.

¹² Dossierstuk 17, met kenmerk 7130_24, pagina 5 en 6.

¹³ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41.

21. Allereerst zendt de medewerker van RMC een e-mail aan de heer [C]:

'[vertrouwelijk], [NMa: de heer [C]]

Dit zijn leerlingen die wij altijd al reden. Ik neem aan dat wij deze kunnen behouden.

(..)

Mvgr

[vertrouwelijk]' [NMa: medewerker RMC]

22. Hierop reageert de heer [C]als volgt: (Onderstreping NMa):

'[vertrouwelijk], [NMa: medewerker RMC]

(..)

De afspraak was ieder eigen gebied dus dit valt onder mij ik heb Breda al gegund gekregen dus gaarne niet onder de prijs door er licht ook een offerte voor de andere ritten en den haag gaat ook apart

(..)

Dus conform afspraak graag.

Ik stuur cc [vertrouwelijk] [NMa: de heer [A]].

[C]

23. RMC kan zich niet vinden in de reactie van de heer [C][en zendt hem wederom een e-mail:

'Beste [vertrouwelijk], [NMa: de heer [C]

Afspraak was, ieder eigen gebied met uitzondering van de contracten die wij al hadden (Onderstreping NMa) (en voor zover bekend was). Die rit naar Breda en Spijkenisse en Zoetermeer doen wij al jaren. (..) Dus wij hebben recht op de ritten Capelle. Ben jij het er niet mee eens, dan offreren we gewoon onafhankelijk van elkaar.

Met vriendelijke groet,

[vertrouwelijk]' [NMa: medewerker RMC]

24. Vervolgens reageert de heer [C] (Onderstreping NMa):

'[vertrouwelijk] [NMa: medewerker RMC]

Dit is wel de afspraak ik rij die zoetermeer [sic] ed en voorts al tijden tot vorig jaar hebben juli [sic] ze gereden daarna is er een overeenkomst de datum 18 dec 2007 gemaakt als juli [sic] Die afspraak niet kunnen of willen nakomen dan is het ons ook vrij om op vom in te schrijven ik denk dat dit niet de bedoeling is van onze afspraken.

Met vriendelijke groet,
[vertrouwelijk] **[NMa: de heer [C]]**

25. Ten slotte stuurt RMC op haar beurt aan de heer [C] de volgende e-mail:

'Beste [vertrouwelijkheid], [NMa: de heer [C]]
Breda, Spijkenisse rijden wij al meerdere jaren achter elkaar, is dus gewoon ons werk. Ik neem
aan dat jij dus het contract respecteert, zoals wij dat ook altijd gedaan hebben.
Met vriendelijke groet,
[vertrouwelijk] **[NMa: medewerker RMC]**

26. Ook uit de gang van zaken bij de aanbesteding van Vervoer op Maat 2008 (VOM) blijkt dat de heer [C] direct betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken. Zo ontvangt de heer [C] op 16 april 2009 een afschrift van de e-mail van de heer [D] waarin de heer [D], mede namens de heer [C], aan de heer [A] (RMC) schrijft over de aanbesteding van VOM.¹⁴

'Goedemiddag [vertrouwelijk], [NMa: de heer [A]]
Tot op dit moment hebben wij nog geen enkel teken van leven gezien van de kant van
Connexxion aangaande het Achmea Zittend Ziekenvervoer in Rotterdam. (..) Dit impliceert
dan wel dat wij, volgens afspraak, (Onderstreping NMa) per 1 mei a.s. mee gaan rijden met
de afgesproken 10 voertuigen in het VOM project. Met wie of wanneer kunnen hier concrete
afspraken over gemaakt worden?
Met groet,
[C]
[D]

27. Hierop reageert RMC met de volgende e-mail:

'[vertrouwelijk], [vertrouwelijk], [NMa: de heren [C] en [D]]
Ik heb tijdens de opening van jullie schadeafdeling nadrukkelijk met [vertrouwelijk]
afgesproken dat de definitieve keuze nu gemaakt is en dat we nu niet meer gaan veranderen.
Wij moeten immers naar de opdrachtgever VOM wel onze zaken voor elkaar hebben en wij
hebben de uren en wagens inmiddels toebedeeld aan [vertrouwelijk].
(..)
Met vriendelijke groet,
[A]

¹⁴ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41, bijlage 12.

28. IJsselsteden reageert hierop als volgt:

‘Goedemorgen [vertrouwelijk], [NMa: de heer [A]]

(..) Wij hebben begrip voor jullie situatie en begrijpen ook dat er, na wisselingen van de wacht aan de Keenstraat¹⁵, veranderingen zijn ontstaan. Deze veranderingen kunnen er volgens ons echter niet toe leiden dat wij met lege handen achter blijven. Volgens ons zijn wij de in jullie offerte met naam genoemde onderaannemer waarmee de RMC destijds op deze aanbesteding VoM heeft ingeschreven. Deze afspraak volgde destijds voort uit onze toezegging om niet zelf of in combinatie met een of meerdere andere partijen op dit project in te schrijven. Ook is de RMC schriftelijke contractuele afspraken met ons aangegaan om een (gedeelte) van het VoM project i.c.m. met de RMC uit te voeren.’(Onderstropping NMa)

29. De betrokkenheid bij de uitvoering van de afspraken van de heer [C] komt ook naar voren bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer in Krimpen. Zo heeft de heer [C] op 8 maart 2010 overleg met de heer [A] (RMC) over wie welke percelen gaat rijden bij het leerlingenvervoer in Krimpen. Dit volgt uit een interne e-mail van de heer [A]:

‘Beste mensen,

Zojuist nog even gesproken met [C].

(...)

Afgesproken met [vertrouwelijk] dat de RMC inschrijft op beide percelen. IJsselsteden wordt dan onderaannemer voor het noordelijk perceel en RMC rijdt zelf het zuidelijke perceel.

(...),¹⁶

30. Uit het bovenstaande volgt dat de heer [C] in ieder geval de wetenschap had van de afspraken die de overtreding van RMC en IJsselsteden vormen. Naast de wetenschap volgt uit de feiten tevens dat de heer [C] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming en de uitvoering van de afspraken. Vast staat ook dat de heer [C] niets heeft gedaan om de gedraging van RMC en IJsselsteden te stoppen.

IV. Beoordeling

31. De Raad wijst erop dat hij in zijn besluiten met kenmerk 7130/153 , heeft vastgesteld dat IJsselsteden artikel 6 Mw heeft overtreden. In dit besluit heeft de Raad bovenstaande argument dat geen sprake zou zijn van mededingingsrechtelijk verboden gedragingen reeds

¹⁵ RMC en RTC zijn aan de Keenstraat in Rotterdam gevestigd.

¹⁶ Dossierstuk 59, met kenmerk 7130_41: bijlage 16.

behandeld en weerlegd. Met betrekking tot het feitelijk leidinggeven door de heer [C] oordeelt de Raad als volgt.

32. De heer [C] is in de periode 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010 [leidinggevende] van IJsselsteden, in welke hoedanigheid [vertrouwelijk]. Hieruit vloeit voort dat de heer [C] [vertrouwelijk].
33. In zijn hoedanigheid als [leidinggevende] van IJsselsteden heeft de heer [C] bij uitstek de hiërarchische en feitelijke positie en de daarbij horende bevoegdheid om gedragingen die leiden tot de overtreding door de IJsselsteden te voorkomen, dan wel vervolgens na aanvang van de overtreding deze ongedaan te maken.
34. De Raad heeft in hoofdstuk 3 van dit besluit vastgesteld dat de heer [C] direct betrokken is geweest bij de totstandkoming van de afspraken die de overtreding van IJsselsteden vormen. De heer [C] heeft op 18 december 2007 persoonlijk de besprekingen met RMC gevoerd over de afspraken, zoals die zijn neergelegd in de overeenkomst van 18 december 2007, en die de basis van de overtreding van IJsselsteden. Daarbij heeft de heer [C] deze overeenkomst ondertekend.
35. Vervolgens heeft de Raad in hoofdstuk 3 van dit besluit vastgesteld dat de heer [C] direct betrokken is geweest bij de uitvoering van de afspraken tussen RMC en IJsselsteden. De heer [C] heeft in zijn hoedanigheid als [leidinggevende] e-mailwisselingen tussen IJsselsteden en RMC gevoerd waarin de afspraken uit de overeenkomst praktisch worden toegepast.
36. Naar het oordeel van de Raad staat daarmee vast dat de heer [C] de gedragingen van de onderneming IJsselsteden bewust heeft aanvaard.

Conclusie

37. De Raad stelt vast dat de heer [C] de gedragingen van IJsselsteden die in strijd zijn met de Mededingingswet niet heeft voorkomen, beëindigd of doen eindigen. Integendeel, hij is zelf direct betrokken is geweest bij die gedragingen en is ook betrokken geweest bij de uitvoering van de afspraken. Vast staat ook dat de heer [C] zelf bevoegd en gehouden was een eind te maken aan de gedragingen van IJsselsteden die de Raad als overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw heeft gekwalificeerd, maar dit niet heeft gedaan.
38. Op grond van het handelen van de heer [C] en het nalaten de overtreding te beëindigen (waartoe hij als [leidinggevende] van IJsselsteden was gehouden), stelt de Raad vast dat de [C] voor de gehele duur van de overtreding van IJsselsteden, van 18 december 2007 tot en met 27 augustus 2010, hieraan feitelijk leiding heeft gegeven.

39. In het licht van het voorgaande kan de heer [C] als overtreder in de zin van artikel 5:1, derde lid, Awb worden aangemerkt.

V. Sanctie

V.I. Beoordelingskader

40. Op grond van artikel 57, eerste lid, Mw, gelezen in samenhang met artikel 5:1, derde lid, Awb, kan de Raad, wanneer een overtreding gepleegd is door een rechtspersoon, een bestuurlijke boete van ten hoogste EUR 450.000 opleggen aan degenen die tot de overtreding opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. De nadere invulling van de factoren waarmee bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening wordt gehouden, is aan de Raad overgelaten. Hierbij dient hij rekening te houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
41. Met betrekking tot de hoogte van een boete heeft de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 5d Mw beleidsregels vastgesteld om de Raad richting te geven bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het opleggen van boetes. Omdat de overtreding na 1 oktober 2009 heeft voortgeduurd, zijn de Boetebeleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009 ("Boetebeleidsregels") van toepassing.¹⁷
42. De Raad stelt op grond van artikel 11, tweede lid, van de Boetebeleidsregels een boetegrondslag vast die is gerelateerd aan de ernst van de overtreding en het inkomen en vermogen van de overtreder, teneinde tot een bestuurlijke boete te komen die zowel uit het oogpunt van algemene preventie als uit het oogpunt van specifieke preventie voldoende afschrikwekkend is. De boetegrondslag is de basisboete.
43. Ingevolge artikel 11, vierde lid, onderdeel b, van de Boetebeleidsregels wordt de boetegrondslag voor natuurlijke personen voor het feitelijk leiding geven aan een overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw vastgesteld binnen de bandbreedte van 50.000 - 400.000 euro. De boetegrondslag wordt binnen deze bandbreedte gerelateerd aan de ernst van de overtreding van zowel de rechtspersoon als de feitelijk leidinggever en de inkomens- en vermogenspositie van die feitelijk leidinggever. Voorts neemt de Raad bij de vaststelling van de bestuurlijke boete boeteverhogende en -verlagende omstandigheden in aanmerking.¹⁸

¹⁷ Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, *Stcrt.* 2009, nr. 14079.

¹⁸ Artikel 12 Boetebeleidsregels.

V.II. Toepassing

44. Onder verwijzing naar het besluit met kenmerk 7130/153 staat vast dat IJsselsteden zich schuldig heeft gemaakt aan zeer zware overtredingen waarvoor een ernstfactor van 3 is vastgesteld. Met betrekking tot de rol van de heer [C] als feitelijk leidinggever daaraan, overweegt de Raad als volgt.
45. Met inachtneming van de ernst van de overtreding en in aanmerking nemende de financiële positie van de heer [C] stelt de Raad achtereenvolgens de boetegrondslag en de basisboete vast op EUR 1.000. Daarbij kent de Raad gewicht toe aan de positie die de heer [C] inneemt in [vertrouwelijk] IJsselsteden en aan zijn directe betrokkenheid bij de gedragingen die de overtreding van IJsselsteden vormen.
46. De Raad kan de basisboete nog bijstellen, wegens boeteverhogende of –verlagende omstandigheden. De Raad ziet in deze zaak geen aanleiding voor een boeteverhoging dan wel boeteverlaging.
47. Alles overwegende is de Raad van oordeel dat in dit geval een boete van EUR 1.000 voor het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van IJsselsteden zoals vastgesteld bij besluit met kenmerk 7130/153, passend is.

VI. Besluit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

legt aan de heer [C], geboren op [vertrouwelijk] te [vertrouwelijk] een boete op van EUR 1.000.

Datum: 20 november 2012

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

Wg.

Henk Don

Lid van de Raad van Bestuur

*Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.*